

1500559-28.2022.8.26.0545

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Leonardo Marzola Colombini

Comarca: Atibaia

Foro: Foro de Atibaia

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/08/2022

... do réu pela prática do crime de tráfico de drogas, reconhecendo-se, ainda, a causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, inc. V, da Lei de Drogas (transposição de fronteiras estaduais). Requereu, também, o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, do mesmo diploma legal (tráfico privilegiado) e, ainda, a fixação de regime ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Atibaia

Foro de Atibaia

3ª Vara Criminal

Rua Doutor José Roberto Paim, 99, Atibaia-SP - cep 12940-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500559-28.2022.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500559-28.2022.8.26.0545

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2133395/2022 - DEL.POL.PLANTÃO ATIBAIA, 25011619 -

DEL.POL.PLANTÃO ATIBAIA, 2133395 - DEL.POL.PLANTÃO ATIBAIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSUÉ DIAS DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo Marzola Colombini

VISTOS.

JOSUÉ DIAS DA SILVA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06, e está sendo processado porque, no dia 16 de maio de 2022, no horário e no endereço mencionados na denúncia, visando à transposição de fronteiras entre Estados da Federação, teria trazido consigo e transportado drogas, consistentes em 15 tijolos de cocaína (pesando, no total, 18.308 gramas), sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado (fls. 85) e apresentou defesa preliminar às fls. 92/98.

A denúncia foi recebida às fls. 108/111.

Citado (fls. 131), em audiência de instrução e julgamento (fls. 131), foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela Acusação em comum com a Defesa, sendo, ao final, realizado o interrogatório do acusado, conforme gravação audiovisual constante dos autos.

Encerrada a instrução, o Ministério Público, em debates orais, se manifestou requerendo a procedência do pedido acusatório, com a consequente condenação do réu pela prática do crime de tráfico de drogas, reconhecendo-se, ainda, a causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, inc. V, da Lei de Drogas (transposição de fronteiras estaduais). Requereu, também, o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, do mesmo diploma legal (tráfico privilegiado) e, ainda, a fixação de regime inicial fechado para cumprimento da pena.

A Defesa, por sua vez, também em debates orais, requereu a absolvição do acusado. Em caso de condenação, pleiteou o reconhecimento da atenuante genérica da confissão espontânea, bem como da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, do mesmo diploma legal (tráfico privilegiado). Requereu, ainda, o afastamento da causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, inc. V, da Lei de Drogas (transposição de fronteiras estaduais). Por fim, pleiteou a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há preliminares a serem apreciadas.

No mérito, de rigor a integral procedência do pedido acusatório, para o fim de condenar o acusado pelo crime de tráfico de drogas, reconhecendo-se, ainda, a causa especial de aumento de pena prevista no artigo 40, incisos V, da Lei de Drogas (tráfico entre Estados da Federação).

Com efeito, a materialidade do delito restou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 08/10, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 11/12, pelo auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 13/14, pelas fotografias de fls. 31/34, pelos laudos periciais de exame químico toxicológico de fls. 76/78 e 82/84, bem como pela prova oral colhida em audiência.

A autoria, da mesma forma, é inequívoca.

O réu Josué Dias da Silva, na fase policial (fl. 06), confessou a prática delitiva, afirmando que: está passando por sérios problemas financeiros e, em razão disso, acabou aceitando transportar os entorpecentes até a cidade de Belo Horizonte - MG; não sabe o nome da pessoa que o contratou para transportar as drogas; tal pessoa entrou em contato e aceitou transportar os entorpecentes pelo valor de R\$ 1.500,00; ao chegar em Belo Horizonte, deveria aguardar o contato de uma pessoa que o encontraria; ao passar pela cidade de Atibaia o ônibus em que estava foi abordado por Policiais Rodoviários Federais; os policiais vistoriaram a bagagem de diversas pessoas e acabaram encontrando a sua bolsa, a qual havia embarcado no ônibus e continha o entorpecente; tal bolsa foi aberta e a droga encontrada; os policiais perguntaram a diversas pessoas a quem pertencia a droga, sendo que os passageiros o apontaram como sendo o proprietário; os policiais o questionaram e acabou confessando que estava transportando os entorpecentes; somente tomou essa atitude pelo desespero e dificuldade financeira.

Em juízo, voltou a negar a prática delitiva, aduzindo que: possui 32 anos de idade; é autônomo; reside na região do Brás, na cidade de São Paulo; é amasiado; possui um filho; está respondendo a processos criminais por tentativa de furto e estelionato; é culpado da acusação; de fato, estava transportando os entorpecentes; foi contratado para transportar os entorpecentes da rodoviária do Tietê até a rodoviária de Belo Horizonte; cometeu o delito porque estava com dificuldades financeiras; estava com o aluguel da residência atrasado; está muito arrependido; não pretende cometer o delito novamente.

Tal confissão merece ser considerada pelo Juízo, haja vista estar em harmonia com as demais provas carreadas aos autos.

Isto porque o policial rodoviário federal Victor Hugo de Oliveira Costa, em juízo, narrou que: por ocasião dos fatos, estavam realizando operação de combate ao narcotráfico em veículos coletivos; fiscalizaram diversos veículos naquele dia; pararam um ônibus que havia saído da cidade de São Paulo e seguia em direção à cidade de Belo Horizonte/MG; ao ingressarem no ônibus, encontraram aos fundos uma bolsa; questionaram a quem pertencia a bolsa; ninguém se identificou; questionou ao indivíduo que estava abaixo da bolsa; ele indicou outro passageiro, dizendo que ele estava de blusa listrada e havia guardado a bolsa no local; convidaram ele a desembarcar; o motorista confirmou que a bolsa pertencia a ele, relatando que ele chegou atrasado e havia tido dificuldades para carregar a bolsa porque estava pesada; ao questionarem o indivíduo, ele confirmou que lhe pertencia; ele disse que havia sido contratado para transportar os entorpecentes, pela quantia de R\$ 1.500,00, até a cidade de Belo Horizonte; ele disse que estava desempregado e com dificuldades financeiras, motivo pelo qual aceitou a proposta; realizada vistoria, encontraram no interior da bolsa uma grande quantidade de pasta base e cloridrato de cocaína; havia diversos tijolos.

Por fim, corroborando tal relato, o policial rodoviário federal Luciano Tilli, em juízo, asseverou que: por ocasião dos fatos, estavam realizando uma operação de fiscalização; deram ordem de parada a um ônibus que havia saído da cidade de São Paulo e seguia em direção à cidade de São Francisco/MG; ao ingressarem no ônibus, encontraram aos fundos uma bolsa; questionaram a quem pertencia a bolsa; ninguém se identificou como proprietário da bolsa; havia 18 tijolos de cocaína dentro da mala; um passageiro, sentado ao fundo, passou a descrição da pessoa que deixou a mala no local; ele descreveu a roupa do acusado; o motorista confirmou que o acusado havia adentrado o ônibus com a mala; ao questionarem o acusado, ele confirmou que lhe pertencia; ele disse que havia sido contratado para transportar os entorpecentes, pela quantia de R\$ 1.500,00, da cidade de São Paulo até a cidade de Pouso Alegre.

Nesse contexto, dúvidas não restam acerca da caracterização do crime de tráfico de drogas, pelos seguintes motivos: i - expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (15 tijolos de cocaína, pesando, no total, 18.308 gramas); ii - confissão informal do acusado no momento da abordagem policial; iii - confissão do acusado em juízo (confirmou a propriedade de todos os entorpecentes e confessou que estava transportando os entorpecentes da cidade de São Paulo/SP até a cidade de Belo Horizonte/MG pela quantia de R\$ 1.500,00 para fins de tráfico de drogas); iv - depoimento harmônico dos policiais rodoviários federais Victor e Luciano, que confirmaram a apreensão do entorpecente no interior de um ônibus que seguia para a cidade de Belo Horizonte/MG; v - apreensão de relativa quantia em dinheiro em poder do réu (R\$ 222,00), sem comprovação da origem lícita.

Com efeito, o acusado, em juízo, confessou que todos os entorpecentes apreendidos (15 tijolos de cocaína, pesando, no total, 18.308 gramas) lhe pertenciam, bem como confessou que estava transportando os entorpecentes da cidade de São Paulo/SP até a cidade de Belo Horizonte/MG.

Além disso, o acusado confessou que receberia pelo transporte dos entorpecentes a

quantia de R\$ 1.500,00, aduzindo que aceitou a proposta por estar passando por dificuldades financeiras.

Tal confissão, a toda evidência, merece ser considerada pelo Juízo como meio de prova, nos termos do art. 197, do Código de Processo Penal, haja vista se encontrar em consonância com as demais provas carreadas aos autos, mormente com o depoimento dos policiais rodoviários federais.

Nesse viés, destaco que policiais rodoviários federais Victor e Luciano, tanto em solo policial quanto em juízo, de forma coesa e verossímil, relataram que abordaram o acusado no interior de um ônibus, tendo encontrados na bolsa dele vários tijolos de cocaína.

Ainda, referidos policiais rodoviários federais relataram que o acusado confessou informalmente que a droga lhe pertencia, bem como que estaria transportando os entorpecentes da cidade de São Paulo até cidade de Belo Horizonte/MG, tendo ele aduzido, ainda, que receberia pelo transporte a quantia de R\$ 1.500,00.

Ademais, insta ressaltar que não há que se falar em ausência de credibilidade no relato dos policiais rodoviários, na medida em que, na condição de testemunhas, suas palavras ostentam o mesmo valor probatório que o de qualquer outra, não se podendo retirar a boa-fé pelo só fato de serem agentes de segurança. Nesse sentido:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-la pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar, tal como ocorreu com as demais testemunhas, que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF, HC nº 74.608-0-SP, rel. Min. Celso de Mello).

Na verdade, o testemunho de policiais merece fé até prova em contrário (RT 426/439), desde que não fique demonstrada a sua inidoneidade (RT 444/406), ou o seu propósito deliberado de incriminar falsamente o réu (RT 454/422), o que não se verificou na hipótese dos autos, até mesmo porque os agentes policiais sequer conheciam o acusado anteriormente aos fatos.

Dessa forma, diante das provas carreadas aos autos e do panorama fático acima descrito, dúvidas não restam acerca da caracterização do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

No mais, destaco que houve a devida caracterização da causa especial de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, em virtude de o tráfico ter se caracterizado entre estados da Federação (São Paulo e Minas Gerais).

Nessa esteira, levo em consideração a própria confissão do réu - no sentido de que transportava os entorpecentes da cidade São Paulo até a cidade de Belo Horizonte, situada no estado de Minas Gerais -, corroborada pelos depoimentos harmônicos dos agentes policiais (relataram que, informalmente, o acusado confessou que a viagem tinha origem na cidade de São Paulo e destino na cidade de Belo Horizonte/MG).

Devidamente configurada a causa de aumento em análise, suficiente se mostra, no entanto, a fração mínima de 1/6 para o aumento de pena, diante do envolvimento de apenas dois estados da Federação (São Paulo e Minas Gerais).

Nesse âmbito:

“A gradação – de um sexto a dois terços – deve cingir-se ao grau de interestadualidade do crime: quanto maior o número de Estados-membros abrangidos pela atividade do agente, maior deve ser o aumento. Se envolver apenas dois Estados-membros, por exemplo, o aumento de um sexto é suficiente.” (NUCCI, Guilherme de Souza; Leis Penais e Processuais Penais comentadas – vol. 1 – 10 ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 432/433).

Destaco, no mais, que o fato de não ter ocorrido a devida transposição da droga para o Estado destinatário (Minas Gerais) em nada prejudica a caracterização da causa de aumento de pena em questão.

Nesse sentido, consoante ensina Renato Brasileiro de Lima (“Legislação Criminal Especial Comentada”: volume único – 5. Ed. Rev. Atual. e Ampl. – Salvador: JusPODIVM, 2017, p. 1.065):

“[...] é dominante o entendimento no sentido de que não é necessária a efetiva transposição da divisa interestadual. Na verdade, basta a presença de evidências de que a substância entorpecente tinha como destino qualquer ponto além das linhas divisórias estaduais.”.

Também é o entendimento do C. Supremo Tribunal Federal:

“A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser desnecessária a efetiva transposição das fronteiras interestaduais para a incidência da majorante prevista no inciso V do art. 40 da Lei de Drogas, 'bastando a comprovação inequívoca de que a droga adquirida num estado teria como destino outro estado da Federação' (HC 115.893, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje de 04.06.2013”. (RHC 122.598, 2ª T., rel. Teori Zavascki, j. 14.10.2014, Dje-214, Divulg. 30.10.2014, Public. 31.10.2014)

Saliento, ainda, que tal questão restou pacificada pelo C. Superior Tribunal de Justiça com a edição da Súmula 587, que assim estabelece:

“Para a incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso V, da lei 11.343/06 é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre Estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual.”

Assim sendo, ainda que o réu sequer tenha deixado o estado de São Paulo (foi abordado nesta Comarca de Atibaia), o delito restou caracterizado, sendo desnecessária a efetiva transposição para o estado de Minas Gerais.

Em se tratando de tráfico interno (e não internacional), ainda que entre estados da Federação, dúvidas não há acerca da competência da Justiça Estadual.

Devidamente caracterizado o crime de tráfico de drogas, no mais, revela-se medida de rigor o não reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em virtude do nítido envolvimento do acusado em atividade criminosa, que restou evidenciado em razão da apreensão de expressiva quantidade de drogas (15 tijolos de cocaína, pesando, no total, 18.308 gramas) e de relativa quantia em dinheiro (R\$ 222,00). Outrossim, o acusado confessou, em juízo, que estava comercializando drogas pela quantia de R\$ 1.500,00. Levo em consideração, ainda, o fato de o acusado responder atualmente as outros processos criminais pelos delitos de furto e estelionato, consoante abaixo analisado.

Neste particular, consigno que, ao contrário do quanto aduzido pela Defesa em sede de debates orais, o entendimento da jurisprudência é firme no sentido de a quantidade de entorpecentes poderem ser utilizadas, dentre outros elementos, como indicativos de envolvimento do agente em atividade criminosa, afastando, por

consequente, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena em questão.

A propósito, transcrevo ementas de julgados proferidos pelo C. Supremo Tribunal Federal, sempre no sentido de se afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado nas situações acima mencionadas, ante a constatação de dedicação do réu às atividades criminosas:

"Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Paciente surpreendido na posse de pouco menos de 7 (sete) quilos de cocaína na tentativa de embarcar para a Nigéria. Condenação. Dosimetria. Incidência da causa especial de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Dedicação à atividade criminosa reconhecida por instância ordinária. Improriedade do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório da causa e para concluir diversamente. Precedentes. Denegação da ordem. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Habeas corpus concedido de ofício. 1. A negativa de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 pelas instâncias ordinárias não está lastreada em presunções, ilações ou conjecturas. Pelo contrário, apresentaram elas elementos concretos que apontam não só que o paciente atuou conscientemente a rogo de organização criminosa, como também se dedicava à atividade ilícita, ficando demonstrado que ele teria realizado outras viagens em circunstâncias indicativas de transporte de drogas. 2. Tal qual se deu na espécie, "a quantidade e a natureza do entorpecente, os apetrechos utilizados e as circunstâncias em que a droga foi apreendida podem constituir o amparo probatório para o magistrado reconhecer a dedicação do réu à atividade criminosa" (HC nº 119.053/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/14). 3. A invocação pelas instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava à atividade criminosa obsta, de fato, a aplicação da benesse do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo certo que afastar essa premissa demandaria o reexame dos fatos e das provas, o qual o habeas corpus não comporta. Precedentes". (STF, HC 141292/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Julgado 15/04/2017, Publicado em 22/05/2017)

"Na hipótese, destacou o Tribunal de origem que a quantidade de droga apreendida (3 quilos de cocaína) evidencia o seu grau de envolvimento com o tráfico de drogas, distinguindo-o, portanto, do traficante ocasional. Para efeitos de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006: a conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas". (STF, RHC 94.806/PR, 1ª Turma, Rel. Min. Carmen Lúcia, DJe 16/04/2010)

Ainda no mesmo sentido, ensina Renato Brasileiro de Lima ("Legislação Criminal Especial Comentada", 2ª edição, Editora Jus Podivm, 2014, p. 743/744) que: "Da mesma forma, se o indivíduo for flagrado com grande quantidade e variedade de drogas, tem-se aí forte indicativo de que se trata de agente dedicado a atividades criminosas, até mesmo porque não é normal que um traficante pequeno e eventual dê início às atividades de traficância com tamanha quantidade e diversidade de drogas".

Ademais, conforme se verifica da pesquisa SIVEC de fl. 35/37 e certidão de fls. 38/39, o acusado responde a duas ações penais devido à prática, em tese, dos crimes de tentativa de estelionato e tentativa de furto. Dessa forma, com base em tais informações, constato que o acusado, embora primário, não preenche os requisitos legais para a aplicação do redutor supramencionado, na medida em que se revela evidente a sua dedicação a atividades criminosas.

Nesse aspecto, insta sublinhar que a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça tem admitido a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de

modo a afastar o benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. A propósito:

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/06. REQUISITOS CUMULATIVOS. DEDICAÇÃO ATIVIDADE CRIMINOSA. UTILIZAÇÃO INQUÉRITOS E/OU AÇÕES PENAS. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. I - O benefício legal previsto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 pressupõe o preenchimento pelo Réu de todos os requisitos cumulativamente, sendo eles: i) primariedade; ii) bons antecedentes; iii) não dedicação em atividade criminosa; iv) não integrar organização criminosa. II - O crime de tráfico de drogas deve ser analisado sempre com observância ao mandamento constitucional de criminalização previsto no artigo 5º, XLIII, da Constituição Federal, uma vez que se trata de determinação do constituinte originário para maior reprimenda ao delito, atendendo, assim, ao princípio da vedação de proteção deficiente. III - Assim, é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica à atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06. IV - In casu, o Tribunal de Justiça afastou a causa de diminuição de pena mencionada em virtude de o Réu ostentar condenação por tráfico de drogas não transitada em julgado, considerando que ele se dedica à atividade criminosa por não desempenhar atividade lícita, bem como porque "assim que saiu da cadeia, voltou a praticar o mesmo delito". Embargos de divergência providos para prevalecer o entendimento firmado no acórdão paradigma, restabelecendo o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça.” (EResp 1431091/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 01/02/2017)

Neste particular, a fim de evitar “bis in idem” na utilização de elementos idênticos em fases distintas da dosimetria, este Juízo não considerará, na 1ª fase, a diversidade e a quantidade de drogas, que serão consideradas, portanto, para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Outrossim, ainda que não aduzido de forma expressa pela Defesa, sublinho que a alegação do réu, de que estava passando por dificuldades financeiras à época dos fatos (tese de autodefesa), não se revela suficiente, no caso em tela, para eventual reconhecimento da excludente de ilicitude do estado de necessidade.

Acerca do assunto, ensina Cleber Masson (“Código Penal Comentado”, Editora Método, 3ª edição, 2015, p. 195/196), ao comentar a distinção entre a referida excludente (estado de necessidade) e as dificuldades econômicas, que: “Não se confundem. No estado de necessidade, o agente é compelido a praticar o fato típico, para afastar a situação de perigo atual ou iminente, involuntário e inevitável, capaz de afetar bem jurídico próprio ou de terceiro, cujo sacrifício é inexigível. Na dificuldade econômica supõe-se que o indivíduo deva conformar-se com a privação, porque não se cuida do suprimento de necessidade vital ou primária, ou, ainda que disso se trate, que lhe seja possível satisfazer a carência por meio de atividade lícita. Em qualquer das hipóteses não se justifica a lesão ao interesse de outrem. Destarte, a dificuldade econômica, inclusive com a miserabilidade do agente, não constitui estado de necessidade. Em casos excepcionais, admite-se a prática de um fato típico como medida inevitável, ou seja, para satisfação de necessidade estritamente vital que a pessoa, nada obstante seu empenho, não conseguiu superar de forma lícita, a exemplo do furto famélico, em que o sujeito subtrai alimentos básicos para saciar a sua fome ou de pessoa a ele ligada por laços de parentesco ou de amizade. Portanto, se o agente podia laborar honestamente, ou então quando se apodera de bens supérfluos ou em quantidade exagerada, afasta-se a justificativa”.

No mesmo sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça também decidiu que:

“Estado de necessidade – dificuldades financeiras – não caracterização: a afetação da qualidade de vida, mesmo implicando em dificuldades financeiras, por si só, não

preenche os requisitos do status necessitatis (art. 24 do CP)" (REsp 499.442/PE, rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 24.06.2003)

Ademais, imperioso destacar que o acusado não comprovou a existência de dificuldade econômica e de perigo atual que justificassem o sacrifício de bem alheio, ônus da prova que, a toda evidência, lhe competia (art. 156, do Código de Processo Penal).

Em outras palavras, a conduta do acusado não se amoldou às condições necessárias ao reconhecimento do estado de necessidade, razão pela qual se revela impossível o seu reconhecimento no caso concreto.

Destarte, diante das provas carreadas aos autos, impõe-se a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, reconhecendo-se a causa de aumento prevista no art. 40, inc. V, da Lei de Drogas, e afastando-se, por outro lado, a causa especial de diminuição de pena concernente ao tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33, da Lei de Drogas).

Verificadas, assim, materialidade e autoria delitivas do crime descrito na inicial acusatória, passo, pois, à fixação da pena a ser imposta à acusada.

Na dosagem da pena-base, nos termos do artigo 42, da Lei de Tóxicos, verifico que o dolo e as demais circunstâncias do crime permaneceram na previsibilidade do tipo legal e nada tiveram de excepcional que autorizassem a exasperação da reprimenda, observando-se que a quantidade e natureza das drogas foram consideradas apenas na fixação da fração do tráfico privilegiado (3ª fase), a fim de evitar "bis in idem". Assim, fixo a pena-base no mínimo legal de 05 anos de reclusão, e 500 dias-multa.

Na segunda fase, verifico a incidência da atenuante genérica da confissão espontânea, de forma que mantenho a pena no mínimo legal (05 anos de reclusão e 500 dias-multa), uma vez que tal atenuante não possui o condão de reduzir a pena aquém do mínimo, nos termos da Súmula 231, do C. Superior Tribunal de Justiça. No mais, destaco que o acusado é tecnicamente primário, cf. pesquisa SIVEC de fl. 35/37 e certidão de fls. 38/39.

Finalmente, na terceira fase, em virtude da incidência da causa especial de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas, aumento a pena em 1/6, totalizando 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa. Acerca do tráfico privilegiado, discorri acima.

Torno definitiva a pena acima.

O dia-multa será fixado em seu mínimo legal, ante a ausência de informações específicas acerca da situação financeira do acusado, salvo aquela fornecida por ocasião de seu interrogatório judicial, insuficiente para tal finalidade.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, fixo, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal, o fechado, em que pese a primariedade técnica do réu e o fato da pena privativa de liberdade não ter ultrapassado 8 anos, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta do acusado (transporte de enorme quantidade de entorpecentes - 15 tijolos de cocaína, pesando, no total, 18.308 gramas -, visando à transposição de fronteiras entre os estados da Federação), não desconhecendo este Juízo, todavia, a recente tese de Repercussão Geral fixada pelo C. Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do ARE 1052700, de relatoria do Exmo. Ministro Edson Fachin, no sentido da inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei dos Crimes Hediondos. Ademais, a fixação de regime inicial mais brando não alcançaria, de forma expressiva, os objetivos de repressão e prevenção visados pelo Direito Penal.

Destaco, ademais, que não se mostra cabível a conversão da pena privativa de

liberdade em restritiva de direitos, tendo em vista a quantidade de pena aplicada ao réu (superior a 04 anos) – art. 44, inc. I, do Código Penal. Ainda, de se observar que tal medida não se mostra socialmente recomendável no presente caso, tendo em vista a sua gravidade em concreto – requisitos subjetivos (art. 44, inc. III, do Código Penal).

O réu não poderá apelar em liberdade, uma vez presentes os requisitos que culminaram com a decretação de sua prisão preventiva. A detração, para fins de eventual progressão (o réu se encontra preso preventivamente há menos de três meses), deverá ser melhor analisada pelo Juízo das Execuções, inclusive em sede de execução provisória, não vislumbrando o Juízo da condenação motivo plausível e evidente para alteração do regime inicial de cumprimento das penas privativas de liberdade, nos termos do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

ANTE O EXPOSTO, julgo INTEGRALMENTE PROCEDENTE o pedido acusatório constante da ação penal proposta pelo Ministério Público contra JOSUÉ DIAS DA SILVA e assim o faço para CONDENÁ-LO como incurso no artigo 33, caput, c.c o artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06, aplicando-lhe a pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa, calculada a fração do dia-multa no trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, com correção desde a sua ocorrência, em regime inicial fechado, sem conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito, e sem o direito de apelar em liberdade.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, oficiando-se para tanto.

Com o trânsito em julgado:

I - lance-se o nome do réu no rol dos culpados e oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral para os fins previstos no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal (suspensão dos direitos políticos); e

II – oficie-se ao FUNAD com relação ao numerário depositado a fls. 60, cuja perda ora decreto, haja vista ter restado comprovada a origem ilícita do montante.

O réu está isento do pagamento de custas processuais, pois se encontra assistida por Defensora nomeada em razão do convênio firmado entre a OAB/SP e a DPE/SP (fls. 87), presumindo-se, assim, o seu estado de miserabilidade e a impossibilidade financeira de arcar com tal despesa. Após a confirmação da interposição ou não de recurso, expeça-se certidão de honorários em favor da Defensora nomeada.

P.I.C.

LEONARDO MARZOLA COLOMBINI
- Juiz de Direito -

Atibaia, 05 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA